



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2019.0000415156

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1003825-02.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante MOANA RAMALHO SILVA, são apelados RODRIGO DA SILVA GUEDES e MARIA ELENA DA SILVA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Negaram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MAIA DA CUNHA (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E ENIO ZULIANI.

São Paulo, 28 de maio de 2019.

Alcides Leopoldo
Relator
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL

Processo n.1003825-02.2016.8.26.0348

Comarca: Mauá (3ª Vara Cível)

Apelante: M. R. S.

Apelados: R. da S. G. e outro

Juiz: Glauco Costa Leite

Voto n. 16.130

Segredo de Justiça

EMENTA: GUARDA – BUSCA E APREENSÃO DE MENOR – Sentença “extra petita” – Inexistência - Prevalência dos interesses da menor – Guarda em favor da avó paterna que deve prevalecer – Improcedência da busca e apreensão - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Trata-se de ação de busca e apreensão de menor, afirmando a requerente que é mãe e guardiã legal da filha, e que o requerido, pai da criança, a retirou para visitação no dia 12/04/2016 e não a devolveu na data acordada, alegando maus tratos por parte da requerente, que não teve mais notícias da filha, pretendendo a busca e apreensão da filha.

A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente a ação, decretando a guarda provisória da menor J. R. S. G em favor de M. E. S., avó paterna, condenando a autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça (fls. 451/456).

A requerente apelou afirmando ser a sentença “extra petita”, pois concedeu a guarda provisória da menor à avó paterna sem que qualquer uma das partes tenha arguido essa questão, e no mérito, aduziu que não há nos autos nenhuma evidência que justifique a modificação da guarda, pois a criança nos estudos sociais e laudos psicológicos afirma que por vezes



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

a família paterna a manipulava e induzia a prestar depoimento contra a genitora, não havendo prova de maus tratos pela apelante, havendo indícios de alienação parental, pois a menor admitiu que mentiu em depoimentos por orientação dos parentes paternos, que ameaçam a criança de nunca mais ver o pai, restando claro o interesse da menor em permanecer com sua genitora, requerendo a reforma (fls. 490/499).

Foram apresentadas contrarrazões, sustentando-se a manutenção da sentença (fls. 517/525).

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 556/560).

É o Relatório.

Não há sentença *extra petita*, pois na fixação da guarda o juiz observará o interesse da menor, consoante os parâmetros dos arts. 4º e 19 do ECA, destinando-a a quem melhor pode garantir a proteção e o desenvolvimento sadio e adequado à criança ou adolescente.

No mais, como preleciona a professora Ana Carolina Silveira Akel¹, a guarda é "um dos atributos do poder familiar, referindo-se à custódia natural, vale dizer, à proteção que é devida aos filhos, por um ou ambos os pais, constituindo um conjunto de deveres e obrigações que se estabelece entre um menor e seu guardião, visando seu desenvolvimento e sua integração social".

Quanto ao seu estabelecimento, como adverte Milton Paulo de Carvalho Filho², havendo ou não consenso entre os genitores,

¹ AKEL, Ana Carolina Silveira. Guarda Compartilhada: Um Avanço para a Família. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, p.76.

² CARVALHO FILHO, Milton Paulo de. Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência. Coord. Cezar Peluso. 6ª ed. Barueri: Manole, 2012, p. 1.738.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

unilateral ou compartilhada: "sempre se decidirá tendo-se em vista os interesses dos menores, podendo, por esta razão, ser modificada a decisão a qualquer tempo, desde que a ocorrência de fato relevante e grave a justifique".

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Direito da criança e do adolescente. Recurso especial. Ação de guarda de menores ajuizada pelo pai em face da mãe. Prevalência do melhor interesse da criança. Melhores condições. - Ao exercício da guarda sobrepõe-se o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que não se pode delir, em momento algum, porquanto o instituto da guarda foi concebido, de rigor, para proteger o menor, para colocá-lo a salvo de situação de perigo, tornando perene sua ascensão à vida adulta. Não há, portanto, tutela de interesses de uma ou de outra parte em processos deste jaez; há, tão-somente, a salvaguarda do direito da criança e do adolescente, de ter, para si prestada, assistência material, moral e educacional, nos termos do art. 33 do ECA. (...) - A guarda deverá ser atribuída ao genitor que revele melhores condições para exercê-la e, objetivamente, maior aptidão para propiciar ao filho afeto não só no universo genitor-filho como também no do grupo familiar e social em que está a criança ou o adolescente inserido, saúde, segurança e educação. - Melhores condições, para o exercício da guarda de menor, evidencia, acima de tudo, o atendimento ao melhor interesse da criança, no sentido mais completo alcançável, sendo que o aparelhamento econômico daquele que se pretende guardião do menor deve estar perfeitamente equilibrado com todos os demais fatores sujeitos à prudente ponderação exercida pelo Juiz que analisa o processo. (...)” (REsp n. 964.836-BA, 3ª Turma, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 02.04.2009).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A apelante afirma que a menor manifesta desejo de voltar a residir com a mãe e que o pai teria abusado sexualmente da filha, fato este que não restou comprovado na esfera policial e é negado pelo requerido.

O que se pode concluir da extensa prova pericial produzida é que a criança parece estar influenciada, ora pelo pai, ora pela mãe, alternando discursos que se contradizem com relação às supostas violências sofridas.

A Assistente Social em seu laudo pericial asseverou: “ A menina J. trouxe também a informação de que, quando morava com a genitora, mentiu sobre maus tratos sofridos, para que pudesse conviver com a família paterna” (fls. 423) e já a Psicóloga, por sua vez, concluiu que “Também pôde ser observado que, enquanto J. falava sobre a situação de abuso do pai contra si, a linguagem corporal, ou seja, a comunicação não verbal, os gestos e as expressões faciais, eram incompatíveis com o que estava sendo dito. Neste caso, a criança, ao falar sobre o assunto 'abuso', o trazia esboçando sorriso e bocejando, vez ou outra, sem demonstrar indícios de sofrimento psíquico” (fls. 408).

Diante de tal quadro, inegável que o maior prejuízo que se verifica é para a própria criança, concluindo a Psicóloga que “Ante o exposto, a partir das entrevistas clínicas, podemos concluir que a dinâmica familiar tem causado prejuízos emocionais à criança, fazendo com que o relacionamento dessa com o ambiente externo ocorra de modo artificial e visando a satisfação de seus desejos, ainda que para isso, tenha de fazer uso de atitudes que possam prejudicar outrem. (...). Ideal seria que os pais pudessem compartilhar a guarda, de modo que a criança pudesse ter acesso e desfrutar do convívio com ambos os genitores e com os demais familiares.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Neste momento, os avós paternos ainda denotam melhores condições de assistir a criança em suas necessidades biopsicosociais" (p.409), conclusão esta que foi acompanhada pelo Estudo Social (fls. 425).

Assim, de forma a preservar o melhor interesse da menor, a sentença deve ser mantida pelos seus judiciosos fundamentos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Pelo exposto, **NEGA-SE PROVIMENTO** ao recurso.

Alcides Leopoldo
Relator
Assinatura Eletrônica